

1500332-38.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Simone Rodrigues Valle

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/09/2022

... ficar configurado o delito de tráfico de drogas, ainda que o agente não tenha sido surpreendido praticando atos de comércio, como no presente caso.

É o que basta para a procedência da ação quanto ao crime de tráfico, não havendo que se falar em insuficiência probatória, pois as provas são seguras para a condenação do réu.

Quanto ao crime de resistência, este também restou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500332-38.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500332-38.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2076667/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 23724444 -

DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2076667 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS JUNIO LINS DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Simone Rodrigues Valle

Vistos.

CARLOS JUNIO LINS DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 329, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 20 de março de 2022, às 00h50, na Rua Humberto Wanderlei de Souza Leme, 10, Nicola 3, Residencial Hípica Jaguari, nesta cidade e

Comarca de Bragança Paulista, o acusado trazia consigo, para consumo de terceiros e fornecimento alheio, 52 (cinquenta e dois) papелotes de cocaína, pesando aproximadamente 45g; 13 (treze) pedras de crack, pesando aproximadamente 2,6g e 8 porções de maconha, pesando aproximadamente 30g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 1.478,00 em dinheiro. Houve aditamento à denúncia para constar o réu como incurso nas penas do artigo artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 329, do Código Penal.

O acusado foi devidamente notificado (fls. 166/167) e apresentou resposta à acusação às fls. 138/158.

Após, a denúncia e o aditamento foram recebidos, em 19 de abril de 2022, às fls. 168/174.

Durante a audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, uma testemunha arrolada pela defesa e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 210).

Encerrada a instrução, o Ministério Público se manifestou em debates orais, oportunidade em que requereu a procedência da ação, nos exatos termos da denúncia e aditamento. Manifestou-se sobre a dosimetria da pena (fls. 210).

A Defesa, por sua vez, se manifestou às fls. 212/237, alegando, inicialmente, ilicitude na prisão feita pelos guardas municipais. No mérito, requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, incisos V ou VII, do CPP.

Subsidiariamente, requereu o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, a fixação da pena em seu mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em regime inicial aberto, o direito de recorrer em liberdade, bem como a liberação do dinheiro apreendido.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

De início, não há que se falar em nulidade processual (prisão promovida por agentes da guarda municipal), haja vista que a situação de flagrância delitiva/infracional legitima a atuação de “qualquer pessoa do povo” a proceder à prisão/apreensão, não sendo diferente em relação aqueles agentes que, a despeito de zelarem pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com situações de flagrante delito, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART. 301 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão.” (RHC 14585/SP, HC 129932/SP, Rel. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, j. em 15/12/2009, Dje 01/02/2010).

Assim, não há que se falar em qualquer ilegalidade.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico encontra-se totalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 17/19, pelo auto de exibição e apreensão às fls. 12/13, pelo laudo de constatação preliminar (fls. 14/15) e, em especial, pelos laudos de exame químico toxicológico (fls. 117/124), que apontaram resultados positivos para tetrahidrocannabinol e cocaína nas substâncias entorpecentes apreendidas na ocasião, bem como pela prova oral produzida nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria, também, restou comprovada.

Na fase policial, o acusado disse que era o responsável por guardar a droga, mas que ela foi encontrada na rua e não em sua posse. Negou ter mordido o guarda municipal e alegou que foi enforcado (fls. 23).

Em juízo, negou os fatos. Disse que é usuário de maconha e, na ocasião, estava no local para comprar a droga. Ficou com medo ao ver a guarda, sendo que o rapaz que estava com o interrogado correu. Então, como estava ao lado prédio, entrou no local

a fim de se esconder. Confirmou que subiu as escadas do prédio até o último andar, mas negou ter dispensado uma sacola. Afirmou que não mora no local e que mora cerca de três quadras de lá. Negou ter resistido à prisão, bem como ter mordido o guarda. Disse que assim que foi pego já foi agredido. Afirmou que bateram sua cabeça no extintor e tentaram enforcá-lo. Negou ter confessado informalmente a traficância. Confirmou que disse para o Delegado que guardava a droga, pois apanhou e estava sendo coagido, mas não guardava a droga para ninguém. Confirmou que já teve passagem pela Fundação Casa por tráfico e que já conhecia o GM da Rocam, Henrique, que sempre agride o interrogado.

A testemunha Alex Tony Costa, guarda municipal, disse que realizavam fiscalização com uma equipe composta por várias viaturas, pois era época de fiscalização contra perturbação do sossego em bares locais. Ao chegarem no local, ponto conhecido como de tráfico de drogas, perto do condomínio, visualizaram o acusado sentado na calçada com outro indivíduo, conversando e, ao avistarem a viatura, levantaram-se e começaram a andar rapidamente, o que chamou a atenção da guarda. Ao desembarcarem da viatura para abordagem, o réu e o outro indivíduo começaram a correr e adentraram no condomínio, entre os prédios. Como estavam em dois, em dado momento se separaram e os guardas focaram em deter o réu, pois carregava uma sacola. O réu adentrou em um prédio, no qual não residia, e foi até o último andar. Não tendo mais para onde ir, jogou a sacola pela janela. Lograram detê-lo e recuperaram a sacola, a qual continha maconha, cocaína, crack e quase mil e quinhentos reais em dinheiro trocado. Indagado, o acusado confessou a traficância e disse que era seu primeiro dia. Dada voz de prisão, o acusado passou a reagir, desferindo socos e chutes contra os guardas, tentando se desvencilhar, sendo necessário cinco ou seis guardas para contê-lo. Relatou que nenhum guarda ficou ferido e não se recorda se algum dos guardas foi mordido pelo acusado.

No mesmo sentido foi o depoimento de Mauro Pereira Filho, guarda municipal, que acrescentou que o acusado não morava no local e que é muito conhecido pela traficância. Informou que o acusado, inicialmente, nada quis dizer sobre os fatos, mas ao final acabou confirmando o tráfico e que o dinheiro era da venda. Relatou que visualizou o réu com a sacola nas mãos e que, por esse motivo, saiu em seu encalço. Afirmou que a sacola encontrada era a mesma que foi dispensada. Confirmou que o acusado lhe mordeu o braço na hora de algemá-lo e que resistiu à prisão, desferindo socos, chutes, cotoveladas, sendo necessário o auxílio dos demais guardas que estavam no local.

A testemunha de defesa, Luciana Silva de Lima, disse que é moradora do prédio vizinho e, na ocasião, desceu para jogar o lixo e ouviu o réu pedindo ajuda, pois estava sendo agredido por quatro guardas. Tentou intervir, sem êxito. Na sequência, um dos guardas chegou no local com uma sacola plástica. Disse que os guardas ofenderam verbalmente a depoente verbalmente e que foi feito uso de spray de pimenta contra ela. Indagada, negou ter feito qualquer reclamação na Corregedoria da guarda. Relatou que já conhecia o acusado, pois foi vizinha de sua mãe, e que ele não era morador do local.

Por tudo que foi coligido nos autos, tem-se que as palavras do acusado se encontram em dissonância do conjunto probatório, em especial das testemunhas de acusação que, na qualidade de agentes públicos, tais como guardas municipais, possuem fé pública, gozando da presunção relativa de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela Defesa.

Ademais, inverossímil a versão do réu, pois nada há nos autos capaz de indicar que os guardas municipais tenham criado alguma situação para acusar falsamente o acusado, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove a implantação de drogas.

Registre-se, ainda, que a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais e guardas, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que:

“A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”

(RTJ68/64).

E ainda:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (HC nº 74.608-SP/STF).

Assim, ao término da instrução processual verifica-se que a autoria do crime de tráfico ficou devidamente comprovada, até porque os depoimentos dos guardas municipais não foram afastados por qualquer prova produzida pelo réu.

É certo que o acusado foi visto pelos guardas municipais com outro indivíduo em local já conhecido pela traficância e, assim que avistou a guarnição, levantou-se e passou a andar rapidamente, chamando a atenção da guarda. Na sequência, o réu adentrou em um prédio e subiu as escadas até o último andar, ocasião em que ficou encurralado, dispensando uma sacola que portava por uma janela.

Os guardas confirmaram que viram o réu com a sacola e que viram o momento em que o réu a dispensou pela janela que havia no último andar. No mais, confirmaram que a sacola recuperada era a dispensada pelo réu, sem qualquer dúvida.

Recuperada a sacola, em seu interior foram localizados os entorpecentes e quase mil e quinhentos reais em dinheiro trocado.

Assim, a negativa do réu quanto à dispensa da sacola em questão restou isolada nos autos, sendo certo que não há qualquer motivo para que as declarações das testemunhas não sejam consideradas.

Portanto, restou comprovada a propriedade da droga por parte do réu, de modo que resta analisar a sua finalidade e a outra conclusão não se chega senão a finalidade mercantil.

Com efeito, a variedade de droga (52 papелotes de cocaína, 13 pedras de crack e 08 porções de maconha), a forma de acondicionamento (papелotes e trouxinhas), bem como a quantia de R\$ 1.478,00 (um mil quatrocentos e setenta e oito reais) em espécie, sem comprovação de sua origem lícita, comprovam a sua finalidade mercantil.

Por fim, o réu, na fase extrajudicial, confessou que guardava a droga e, quando indagado em juízo, confirmou que assim havia dito para o Delegado, tentando justificar a sua confissão em razão de afirmar que foi coagido, na tentativa de invalidar referida confissão.

Consigno, ainda, que o depoimento dado pela testemunha de defesa demonstra que ela não presenciou todo o ocorrido. Certo ainda que mesmo não sendo indagada acerca de determinados pontos, disse que não era possível que a sacola fosse do réu, apesar de não ter visto o momento da abordagem, o que coloca em dúvida até mesmo a sua imparcialidade, pois afirma algo que não viu. Por fim, quanto à agressão desmotivada que supostamente teria sofrido e presenciado, é de se estranhar que não tenha ido até a Delegacia para dar a sua versão sobre o ocorrido, ou até mesmo ido até a corregedoria da guarda, dizendo ser perseguida no município, descredibilizando sua versão.

Por fim, destaca-se que o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito de tráfico de drogas, ainda que o agente não tenha sido surpreendido praticando atos de comércio, como no presente caso.

É o que basta para a procedência da ação quanto ao crime de tráfico, não havendo que se falar em insuficiência probatória, pois as provas são seguras para a condenação do réu.

Quanto ao crime de resistência, este também restou comprovado.

Consuma-se o delito quando um particular opõe-se a execução de ato legal, mediante o uso de violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

No caso em tela, o acusado, opondo-se à execução de ato legal (abordagem dos guardas e prisão), agrediu os guardas, desferindo-lhes socos e chutes, tendo, ainda, mordido um dos guardas, provocando, desta forma, a ação de cerca de cinco guardas municipais para conter o réu.

Quanto ao crime de resistência, em que pese o relato da testemunha de defesa, não é

crível que seja verdadeiro, considerando o acima exposto.

No mais, a tese da defesa de que o réu agiu em estado de necessidade mediante à ilegalidade do ato não prospera, sendo certo que o ato era legal.

Desta forma, comprovada restou a resistência por parte do acusado para evitar a sua prisão, sendo evidente o dolo do agente de tentar se isentar de responsabilidade do crime de tráfico praticado, se opondo à execução do ato legal.

Por fim, fica afastada a majorante prevista no artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06.

Como se observa nos autos, o acusado foi visualizado na rua e, apesar da proximidade do local com a Escola Estadual João Eernesto de Almeida Vanni, conforme o laudo pericial de fls. 107/109, não restou comprovado que o tráfico foi praticado nas dependências ou imediações destes locais.

Ressalto que a causa de aumento visa coibir com maior rigor a venda da droga nestes locais em razão da maior aglomeração de pessoas, facilitando a disseminação da mercancia.

No caso em tela, porém, é certo que nada foi dito pelas testemunhas acerca da movimentação na rua proveniente da escola, de modo que não restou cabalmente comprovado que o réu se valeu dessa proximidade para a disseminação da venda.

Nesse sentido:

“Porém, a causa de aumento prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06, deve ser afastada. O fato de haver escola, praça pública e campo de futebol nas imediações do local onde foi apreendido o entorpecente, por si só, não tem o condão de majorar a pena do acusado. Teria de haver prova de que o réu estava se valendo dessa proximidade para vender drogas aos frequentadores desses locais, o que não ficou demonstrado nos autos” (Apelação nº 0001050-57.2014.8.26.0362;

Relator (a): Augusto de Siqueira; Comarca: Mogi-Guaçu; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 13/08/2015; Data de registro: 14/08/2015). Resolvido o mérito, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena e atendendo à culpabilidade, à personalidade, à conduta social, às consequências do crime, verifico que não há nenhuma circunstância judicial que justifique a elevação da pena, motivo pelo qual mantenho as penas no seu patamar mínimo, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no valor unitário mínimo legal para o crime de tráfico e em 2 meses de detenção para o crime de resistência.

Na segunda fase, verifico que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos e, assim, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa, contudo, impossível a diminuição da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ), permanecendo as penas acima fixadas.

Na terceira fase, verifico como recomendável seja aplicada a causa de diminuição contida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, principalmente porque essa causa de diminuição da pena subsuma-se à situação do acusado em questão (primário e não se vê a existência de antecedentes efetivos para justificar o impedimento dessa benesse, sem, também, qualquer demonstração de que se dedica à atividade criminosa ou íntegra organização criminosa), motivo pelo qual ela faz jus à redução na metade (1/2). Justifico a redução nesse patamar em razão da variedade da droga encontrada. Assim, estabeleço a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão, além de 250 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Com relação ao crime de resistência, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, tornando-a definitiva por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, anteriormente, ao tratar de casos envolvendo o tráfico de entorpecentes, sempre entendi, em atenção ao disposto no art. 5º, XLIII, da CF, a integral aplicação dos rigores da Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), a qual determina a imposição do regime inicial fechado (art. 2º, § 1º, com redação dada pela Lei nº 11.464/07), e da Lei nº 11.343/06, que veda a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, caput).

No entanto, ressalvada minha convicção pessoal, é necessário levar em consideração que, no âmbito dos Tribunais Superiores, em relação ao tráfico privilegiado, a

Jurisprudência se consolidou para diferenciá-lo do tráfico em sua forma fundamental, tratando-o como delito não assemelhado a hediondo, sempre que preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Nessa ordem de ideias, o Plenário do E. STF, ao julgar o HC nº 118.533/MS, em 23/06/2016, decidiu que: "O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos". Em vista deste precedente, a 3ª Seção do C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, por unanimidade acolheu a tese vitoriosa no STF, revisando o entendimento até então firmado com o enunciado nº 512 daquela Corte, atualmente cancelado (Pet nº 11.796/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016).

Importante destacar, em tempo, as decisões do E. STF que em caráter incidental declararam inconstitucionais, por afrontarem a individualização da pena, tanto a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os crimes hediondos e equiparados (HC nº 111.840/ES, j. 27/06/2012), quanto a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos da Lei de Drogas (HC nº 97.256/RS, j. 01/09/2010), com a consequente promulgação da Resolução nº 5 de 2012 pelo Senado Federal, suspendendo a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Embora proferidas em processos individuais, sem eficácia vinculante, essas decisões da Corte Suprema devem ser observadas, em nome da segurança jurídica e na busca da uniformidade na resolução de conflitos.

Sob essas premissas, passo a analisar o caso dos autos, tendo como objetivo o apenamento proporcional às condições pessoais do infrator e das circunstâncias específicas do comércio ilícito por ele desenvolvido, afastada a hediondez do delito e suas consequências.

O presente caso, enfim, versa sobre a apreensão de 52 papelotes de cocaína, pesando aproximadamente 45 gramas; 13 pedras de crack, pesando aproximadamente 2,6 gramas, e 8 porções de maconha, pesando aproximadamente 30 gramas, na posse de indivíduo primário, sem provas de conexão com as organizações criminosas ou traficância habitual.

Consequentemente, revendo posicionamento anterior e cedendo à orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, fixo o regime inicial ABERTO para a execução da pena privativa de liberdade, nos moldes do art. 33, § 2º, "c", do CP, para os crimes de tráfico e resistência.

Ainda, porque presentes os requisitos correlatos, em atenção ao quantum de pena e à primariedade do réu, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44, § 2º, parte final, do CP.

A primeira consistirá na prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, indicando o Juízo das Execuções tanto o destinatário como a espécie de serviço a ser prestado pelo tempo da pena substituída; a segunda em prestação pecuniária no valor de 02 salários mínimos na época do fato em favor de entidade pública ou privada, com destinação social, também a ser designada pelo Juízo das Execuções. Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que o Ministério Público move contra CARLOS JUNIO LINS DE SOUZA, para, com base no artigo 33, caput, c.c. parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, e o artigo 329, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, CONDENÁ-LO à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, bem como o pagamento de 250 dias-multa no valor unitário mínimo legal, em regime inicial aberto, pelo crime de tráfico de drogas, e à pena de 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de resistência, substituída a pena privativa de liberdade nos termos acima deliberados,

Tendo em vista a natureza da pena, poderá o réu recorrer em liberdade.

Comprovado que o dinheiro apreendido era produto do narcotráfico, decreto seu perdimento em favor da União (fls. 92). Expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Bragança Paulista, 07 de setembro de 2022.

Simone Rodrigues Valle

Juíza Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA